

1509299-49.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte
Comarca: São Bernardo do Campo
Foro: Foro de São Bernardo do Campo
Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Confira-se: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Por derradeiro, o fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509299-49.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509299-49.2021.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3078952/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 20432890 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 20434234 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 3394/2021/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 3376/2021/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ezequiel Rodrigues de Souza Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 20 horas, na Travessa Oriente, altura do nº 29, bairro dos Casa, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo e transportava, droga consistente em 287g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

Segundo o apurado, na data e local acima indicados, o acusado trazia consigo e transportava uma porção individual de maconha, compactada na forma de tijolo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado na condução do veículo VW/Fox, de placas NHL3J28, em atitude suspeita, pois assim que ele notou a aproximação da viatura, acelerou. Por isso, os policiais ordenaram a parada, emitindo sinais sonoros e luminosos.

Não obstante a ordem de parada, o acusado se evadiu do local, e em dado momento abandonou o veículo na via pública e continuou a fuga a pé, não sendo localizado. Então, os policiais procederam a buscas no interior do automóvel, e encontraram um invólucro plástico contendo a referida porção de maconha compactada em formato de um pequeno tijolo, além de uma balança de precisão.

Os bens foram apreendidos e levados à Delegacia de Polícia, onde procedeu-se a pesquisas com fulcro no emplacamento do veículo. O acusado foi identificado, intimado e compareceu ao DP na companhia da proprietária do automóvel, Marlene Maria da Silva.

Na ocasião, ele confirmou os fatos e afirmou ser o proprietário da droga, que se destinava ao seu consumo pessoal, já que é usuário de maconha.

A expressiva quantidade de droga apreendida, a existência de balança de precisão e as demais circunstâncias envolvidas na apreensão evidenciam que a droga se destinava ao tráfico.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 05/25. Notificado (pág.51), o acusado ofertou defesa preliminar (pág.128). Recebida a denúncia (págs. 129/130), o réu foi citado (pág.132). Em instrução, foram ouvidas três testemunhas comuns, interrogando-se o réu.

Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, com elevação da pena e fixação de regime inicial fechado, reconhecida a reincidência; ao passo que a defesa postula pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente praticado pelo acusado, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição, apreensão e entrega a págs.18 (veículo apreendido) e 125/126 (tijolo de maconha e balança de precisão); nos laudos químico-toxicológico (págs.11/13) e pericial de págs. 49/50 (balança de precisão).

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal o acusado admitiu a propriedade do tijolo de maconha localizado dentro do veículo VW/Fox, de placas NHL3J28. Negou, contudo, a prática o crime de tráfico de droga.

Na fase policial, declarou que:

"...que é amigo da família da Senhora Marlene, que sempre pega o carro emprestado com a dona Marlene, que inclusive foi ele que vendeu o carro para ela anteriormente, que no dia do ocorrido pegou o carro emprestado com a Senhora Marlene para levar um familiar ao médico, após chegar do hospital ficou andando com o carro, esclarece que faz uso de entorpecentes "maconha", que no dia do acontecido estava com uma maconha para uso próprio, que quando via uma viatura de polícia da BAEPE se desesperou e saiu correndo com medo por ter maconha consigo mesmo sabendo que era para consumo próprio, sai correndo abandonando o carro e a maconha para trás" (pág.08).

Em Juízo, mantendo a versão anterior, aduziu que conduzia o veículo VW/Fox, de placas NHL3J28, quando se deparou com os policiais militares. Estava na posse do tijolo de maconha e fugiu por medo. Negou, contudo, a prática o crime de tráfico de droga.

Havia pedido o automóvel emprestado à testemunha Marlene para comprar maconha no Jardim Silvina. Para não ter que se dirigir à 'biqueira' por mais de uma vez, comprou o tijolo apreendido nos autos, sendo que toda a maconha apreendida seria para o próprio consumo. Não havia balança de precisão no interior do carro. A negativa de existência do crime de tráfico de droga ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares Alan Roberto Burity Vitulo e Daniel de Jesus Almeida, em relato coeso e harmônico com o anterior, informaram os passos da diligência encetada na data do fato e espancaram qualquer dúvida acerca da existência do crime:

Realizavam patrulhamento ostensivo de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o veículo VW/Fox, de placas NHL3J28, no contrafluxo. A rua era estreita. O condutor não conseguiria passar pela viatura. Agindo de modo suspeito, o condutor do VW/Fox deu marcha ré e quase colidiu com os carros estacionados na via. Em seguida, abandonou o carro e saiu correndo. Não conseguiram alcançá-lo.

Dentro do automóvel localizaram um tijolo de maconha sobre o banco do passageiro. O veículo foi encaminhado à Delegacia e a Polícia Civil encetou diligências para apuração da autoria do crime.

O policial militar não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Inexiste o mínimo indício de que os policiais militares tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câ. Crim., julgado em 27/01/2015).

A Polícia Civil encetou diligências e obteve a qualificação da proprietária do veículo. Ouvida em instrução, Marlene Maria da Silva confirmou que o acusado estava em poder do veículo na data e hora do fato:

Havia comprado o veículo do próprio acusado, recebendo a posse do bem. Buscava regularizar a documentação do automóvel quando, na data do fato, EZEQUIEL lhe pediu o carro emprestado, declarando que precisava socorrer um parente. Não o devolveu. Foi, então, informada por policiais que o veículo havia sido apreendido porque localizada droga dentro dele.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a quantidade de substância entorpecente apreendida (01 tijolo de maconha pesando 287g), a forma como acondicionada (individualmente) e as circunstâncias da prisão (fuga do acusado e abandono do veículo), tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do

citado Diploma.

Consigne-se que, embora o réu não tenha sido preso enquanto efetuava a venda da droga apreendida, tal circunstância, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

A versão defensiva de que o acusado comprara um tijolo de maconha para o próprio consumo não é crível. Fica afastado o pedido defensivo de desclassificação para a conduta de mera posse de droga para consumo próprio.

Ezequiel aduziu que trabalhava em lava-rápido e ganhava a quantia mensal de R\$1.350,00 por mês. Possui companheira e filha de 03 anos de idade. Nesse passo, inverossímil gasto de um terço do salário (R\$450,00) com maconha, de uma única vez, como declarado pelo réu para afastar responsabilidade penal. São conhecidas as despesas básicas para manutenção de uma casa, própria ou alugada, e de membros de uma família, principalmente de criança pequena.

Acrescenta-se, outrossim, que a elevada quantidade de maconha apreendida (tijolo com quase 287g) é apta a produzir inúmeros cigarros individuais de maconha (um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 a 5 cigarros, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes e galhos, conforme se apura nos processos de tráfico de droga julgados nesta Comarca). Ou seja, entre 150 a pouco mais de 500 porções individuais de maconha produziria o tijolo localizado em poder do réu.

Nesse contexto, destaca-se que não há adminículo de prova de dependência química que, ainda que reconhecida, não levaria à subsunção da conduta ao artigo 28 da Lei de Tóxico. A causa excludente da culpabilidade foi afastada pelo próprio acusado, que em seu interrogatório judicial declarou conseguir não consumir droga por vontade própria. Nos autos não há relato de alteração comportamental ou de saúde típica de quadro de dependência química.

Em Juízo, o acusado não apresentou indicativo apto a revelar comprometimento de sua capacidade cognitiva em razão do uso de entorpecentes. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura. Conforme preceitua o art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da *actio libera in causa*, “segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime” (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Ainda nessa quadra, saliente-se que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante. É sabido que, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Por derradeiro, o fato do tijolo ter sido apreendido sobre o banco do passageiro não chancela a tese de que o agente o portava para o próprio consumo. As razões para tal circunstância somente o réu poderia explicar, pois inerente à sua subjetividade, sendo que inúmeras hipóteses poderiam ser aventadas, tais como sentimento de impunidade, negligência na ocultação, distração, dentre tantas. De qualquer modo, tal dado é secundário e não retira a credibilidade do panorama,

francamente incriminador para o reconhecimento de que o tijolo se destinava à mercancia ilícita.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica (art. 33, caput, a Lei nº 11.343/06) e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado. São desfavoráveis as suas condições subjetivas. O réu ostenta condenação anterior e irrecorrível por crime de roubo (autos nº 3002378-26.2013 - 2ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 2015. A pena foi extinta pelo cumprimento em maio/2017, cf.certidão criminal às págs.117/120).

Ainda possui outra condenação por crime de lesões corporais no âmbito da violência doméstica (autos nº 1501740-57.2019 - 1ª Vara Criminal de Diadema. Fato anterior ao apurado nos autos. A condenação transitou em julgado no curso deste processo em 16/03/2022).

Nessa linha:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes” (HC 171.212/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015).

Outrossim, a quantidade de droga apreendida em poder do réu (287g de maconha), torna a sua conduta mais censurável, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social. O crime é de perigo abstrato.

Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a “natureza” (ou “qualidade”) e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes (“HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”.

Assim, diante do acima ponderado, elevo a reprimenda em 1/5, índice proporcional às condições subjetivas do agente, circunstâncias e consequências do delito, o que perfaz 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Reincidente (autos nº 0001027-03.2016 - por crime de furto. Tramitou perante a 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2018. Réu ainda cumpria pena em regime aberto desde 16/02/2018, cf.certidão criminal às págs.117/120), elevo a pena do acusado em 1/6, fixando-a em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Não há atenuantes a considerar (o réu negou o crime de tráfico de droga).

O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e da reincidência na segunda etapa da dosimetria não configura bis in idem, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto

como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no RESp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Não incidem causas de aumento de pena. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos os predicados legais. O RÉU É REINCENTE e ostenta antecedentes criminais.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o fechado. Mostra-se adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito de tráfico, circunstâncias em que foi praticado e suas consequências, que demonstram a periculosidade e ousadia do agente, aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade.

Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

O acusado é reincidente (autos nº 0001027-03.2016 - por crime de furto. Tramitou perante a 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2018) e possui condenações anteriores e irrecorríveis (autos nº 3002378-26.2013 - 2ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 2015. A pena foi extinta pelo cumprimento em maio/2017, cf.certidão criminal às págs.19/25 e autos nº 1501740-57.2019 - 1ª Vara Criminal de Diadema. Fato anterior ao apurado nos autos. A condenação transitou em julgado no curso deste processo, cf.certidão criminal às págs.117/1201). Ainda cumpria pena anterior e definitiva por crime de furto, em regime aberto, quando voltou a delinquir, cf.certidão criminal juntada às págs.117/120.

Nesse passo, regime mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", a par de não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 33, §3º, 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Resultaria ilógica, nesta situação, a aplicação de tais benesses, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes (afastado o tráfico privilegiado), que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, qualificado a pág. 15, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu está preso por outro delito. A este processo respondeu solto. Não alterada a situação fática, permito o recurso em liberdade.

De plano, não impugnados os laudos periciais:

a) e não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos;

b) autorizo a destruição da balança de precisão. Oficie-se à autoridade competente. Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva e efetuando-se comunicações necessárias;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com

sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, as partes para manifestação; Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA